

Lösungsvorschlag zum Fall „Feuchter Keller“:

E könnte einen Anspruch auf Nacherfüllung gegen D gem. §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB haben.

A. Anspruch entstanden

Der Anspruch muss entstanden sein. Dies setzt einen wirksamen Werkvertrag gem. § 631 BGB zwischen F und E voraus.

1. Werkvertrag

F und E müssen zunächst einen wirksamen Werkvertrag gem. § 631 BGB geschlossen haben. F und E vereinbaren die Erstellung eines Werks in Gestalt einer Außenisolierung.

a. Abgrenzung zum Verbraucherbauvertrag

Fraglich ist, ob eventuell ein Verbraucherbauvertrag nach § 650i BGB gegeben ist. Dann müsste die Außenisolierung als erhebliche Umbaumaßnahmen anzusehen sein. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die mit dem Bau eines neuen Gebäudes vergleichbar sind (Grüneberg/ *Sprau* § 650i Rn. 4). Eine Außenisolierung findet zwar am Gebäude statt, lässt sich aber eher als Renovierungsmaßnahme einstufen und ist als punktuelle Schutzmaßnahme nicht mit der Neuerstellung eines Gebäudes zu vergleichen. Somit liegt kein Verbraucherbauvertrag, sondern ein allgemeiner Werkvertrag vor, der ausschließlich nach §§ 631 ff. zu beurteilen ist.

b. Zwischenergebnis

E und F haben einen (einfachen) Werkvertrag i.S.d. § 631 BGB geschlossen.

2. Werkmangel

Das Werk muss einen Mangel aufweisen. Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen (§ 633 Abs. 1 BGB). In Betracht kommt hier ein Sachmangel nach § 633 Abs. 2 BGB.

a. Abweichung von einer vereinbarten Beschaffenheit

Zunächst gilt es zu prüfen, ob ein Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Nr. 1 BGB vorliegt. Das Werk ist nach § 633 Abs. 2 Nr. 1 BGB mangelhaft, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Hierzu müssen sich E und F zunächst über eine bestimmte Beschaffenheit verständigt haben. Vorliegend haben die Parteien sich vertraglich über keine spezifischen Anforderungen verständigt. Ein Sachmangel i.S.d. § 633 Abs. 2 Nr. 1 BGB liegt somit nicht vor.

b. Ungeeignet für gewöhnliche Verwendung

Darüber hinaus kann das Werk einen Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Nr. 2 BGB aufweisen. Das Werk kann nicht für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein. Dies ist der Fall, wenn es sich nicht für Zwecke eignet, für die Werke der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden. Der Zweck von wasserdichten Außenisolierungen besteht darin, Gebäude vor Feuchtigkeit und Wassereintritt zu schützen. Die angebrachte Außenisolierung eignet sich nicht für die gewöhnliche Verwendung i.S.d. § 633 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt. BGB.

c. Abweichung von der üblichen Beschaffenheit

Ferner kann ein Mangel vorliegen, wenn das Werk nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Werken gleicher Art üblich ist (§ 633 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. BGB). Die übliche Beschaffenheit bestimmt sich anhand eines Vergleichs mit Werken derselben Art. Eine wasserdichte Außenisolierung weist üblicherweise eine Beschaffenheit auf, bei der sichergestellt wird, dass kein Wasser eindringen kann. Die vorliegende Außenisolierung weist somit nicht die übliche Beschaffenheit gemäß § 633 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. BGB auf.

d. Zwischenergebnis

Das Werk weist einen Sachmangel gem. § 633 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt. und 2. Alt. BGB auf. Folglich liegt ein Sachmangel vor.

3. Bei Gefahrübergang

Weiterhin muss der Mangel bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Der Gefahrübergang (§ 644 Abs. 1 Nr. 1 BGB) erfolgt mit der Abnahme des Werkes (§ 640 Abs. 1 BGB). Da die Isolierung bereits beim nächsten Regenwetter Undichtigkeiten zeigte, ist davon auszugehen, dass dieser Zustand bereits bei Abnahme des Werkes bestand. Der Mangel lag somit bei Gefahrübergang (§ 644 Abs. 1 Nr. 1 BGB) vor.

4. Kein Ausschluss der Gewährleistungsrechte

Die Mängelgewährleistungsrechte dürfen nicht generell ausgeschlossen sein.

a. Vertraglicher Gewährleistungsausschluss

Eine vertragliche Abrede, welche zu einem Gewährleistungsausschluss führen könnte, ist im vorliegenden Sachverhalt nicht ersichtlich.

b. Gesetzlicher Gewährleistungsausschluss

Vorliegend könnte jedoch ein Ausschluss nach § 640 Abs. 3 BGB in Betracht kommen. Nach § 640 Abs. 3 BGB ist der Anspruch auf Nacherfüllung ausgeschlossen, wenn der Besteller ein mangelhaftes Werk abnimmt, den Mangel kennt und sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme nicht vorbehält. Wie sich aus dem Sachverhalt ergibt, war E zunächst erfreut. Es ist davon auszugehen, dass der E den Mangel bei Abnahme nicht bekannt. Es liegt somit keine Gewährleistungsausschluss nach § 640 Abs. 3 BGB vor.

5. Nacherfüllungsverlangen

Schließlich müsste E Nacherfüllung gegenüber F gem. § 635 Abs. 1 BGB verlangen. Dies ist vorliegend noch nicht geschehen. Damit E gegen F seinen Anspruch auf Nacherfüllung nach §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB geltend machen kann muss E Nacherfüllung verlangen. *Hier- von wird in der Prüfung nachfolgend ausgegangen.*

Der Anspruch des E gegen F auf Nacherfüllung nach §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB ist wirksam entstanden.

B. Anspruch untergegangen

Erlöschensgründe sind im Sachverhalt nicht ersichtlich.

C. Anspruch durchsetzbar

Der Anspruch des E gegen F ist auch durchsetzbar. Insbesondere kommt ein Leistungsverweigerungsrecht der F nach § 635 Abs. 3 BGB hier nicht in Betracht.

Ergebnis:

E hat gegen F einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB. Folglich kann E von F die Nacherfüllung verlangen, was allerdings nicht heißt, dass er eine komplett neue Isolierung beanspruchen kann. Es ist Sache des F zu entscheiden, ob er nur die Mängel

an den undichten Stellen der Isolierung beseitigt oder eine komplett neue Isolierung vornimmt, § 635 I BGB. Die für die Mängelbeseitigung notwendigen Aufwendungen an Arbeit, Material und Transport hat F aber auf jeden Fall zu tragen, § 635 II BGB.

Was die Bezahlung der Vergütung angeht, gilt gem. § 641 III BGB Folgendes: Bis zur Beseitigung des Mangels kann E die Bezahlung eines angemessenen Teils der Rechnung verweigern; dieser beträgt mindestens das Zweifache der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Abwandlung

F kommt mit der Nacherfüllung nicht nach. Was kann E tun?

Zunächst müsste E dem F eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen. Nach vergeblichem Ablauf der Frist hat er folgende Möglichkeiten:

1. Er könnte den Mangel durch ein anderes Unternehmen beseitigen lassen und dem F die entsprechenden Kosten aufgeben. Dieses Recht ergibt sich aus §§ 634 Nr. 2, 637 BGB.
2. Er könnte auch den Rücktritt vom Vertrag erklären, da die Herstellung einer undichten Isolierung eine erhebliche Pflichtverletzung darstellt, §§ 634 Nr. 3, 636, 323 I, V 2 BGB.
3. Er könnte alternativ zum Rücktritt eine Minderung verlangen, §§ 634 Nr. 3, 638 BGB. Das bedeutet, dass er das schadhafte Werk behält und die Herabsetzung der Vergütung beansprucht.
4. Er könnte schließlich Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 634 Nr. 4, 281, 280 BGB geltend machen, wobei dieser Anspruch aber von einem Verschulden des D abhängig ist. Dieses wird nach § 280 I 2 BGB vermutet. Eine Entlastung ist hier nicht ersichtlich. Beim Schadensersatz hat E die Wahl, ob er den kleinen Schadensersatz wählt, also das Werk behält und nur den Minderwert der Isolierung geltend macht, oder aber wegen des erheblichen Mangels den großen Schadensersatz begehrt: dann kann er das Werk zur Verfügung stellen, die gesamte Vergütung zurückfordern und die erhöhten Kosten für anderweitige Herstellung begehren.

Antworten zum Fragenteil:

1. **Erläutern Sie wer bei einem Werkvertrag das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neuherstellung hat und zeigen Sie Unterschiede zum Wahlrecht bei Kaufvertrag auf.**

- Im **Kaufrecht** liegt das **Wahlrecht** im Hinblick auf den Inhalt des Nacherfüllungsanspruchs beim **Käufer** gem. § 439 Abs. 1 BGB.
- Wenn das Werk einen Mangel aufweist, hat der Besteller in erster Linie ein Recht auf Nacherfüllung. Anders als im Kaufrecht entscheidet aber nicht der Kunde, sondern der Unternehmer, ob er den Mangel durch Nachbesserung beseitigt oder ein ganz neues Werk herstellt, § 635 BGB.
- Folglich besteht der Unterschied darin, dass gem. § 635 I der Unternehmer das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neuherstellung hat, während beim Kaufvertrag das Wahlrecht beim Käufer liegt.

2. **Was versteht man beim Werkvertrag unter einem Sachmangel, was unter einem Rechtsmangel? Nennen Sie jeweils auch ein Beispiel.**

- Ein Sachmangel liegt vor:
 - wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, § 633 II 1 BGB. Es gilt also ein subjektiver Fehlerbegriff. Entscheidend ist, was die Parteien konkret vereinbart hatten und ob im Vergleich dazu die tatsächliche Beschaffenheit des Werks damit übereinstimmt oder nicht.

Beispiel: Der Dekan bestellt für den neuen Hörsaal 70 Stühle in Regenbogenfarben. Der Hersteller liefert wie zuvor graue Stühle. Hier entspricht das Werk nicht der vereinbarten Beschaffenheit und ist mangelhaft.

- wenn keine Vereinbarung über die Beschaffenheit des Werks getroffen, kommt es darauf an, ob sich das Werk für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet oder sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und dann eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken gleicher Art üblich ist, § 633 II 2 BGB.

Beispiel: Das neu verlegte Flachdach ist undicht. Hierbei handelt es sich um ein mangelhaftes Werk, da die Dichtigkeit nach dem Vertrag mit dem Dachdecker vorauszusetzen ist.

- Ein Rechtsmangel liegt vor:
 - Wenn Dritte in Bezug auf das Werk Rechte gegen den Besteller geltend machen können, § 633 III BGB. Hier ist vor allem an Urheberrechtsverletzungen zu denken.

Beispiel: Ein Architekt kuppert den Entwurf eines renommierten Kollegen ab und legt ihn dem Bauherrn als eigenen Bauplan vor.

3. Das Fahrrad von Student S hat einen Platten. S bringt es zur Fahrradwerkstatt F und beauftragt diese damit, die Reifenpanne durch das Einsetzen eines neuen Schlauchs zu beheben. Nach der Rückgabe stellt S fest, dass weiterhin Luft aus dem Schlauch seines Fahrrads entweicht. Welche Ansprüche kann S geltend machen?

- Zunächst kann festgehalten werden, dass hier das Werk nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht und ist mangelhaft.
- Wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist, dann liegt ein Sachmangel nach § 633 II 1 BGB vor.
- Es gilt also ein subjektiver Fehlerbegriff. Entscheidend ist, was die Parteien konkret vereinbart hatten und ob im Vergleich dazu die tatsächliche Beschaffenheit des Werks damit übereinstimmt oder nicht.
- S hat gegen F einen **Anspruch auf Nacherfüllung gemäß §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB.**

4. Was verstehen Sie unter einer Selbstvornahme?

- Bei Vorliegen eines Mangels können Primär- und Sekundäransprüche entstehen.
- Im Sinne der sogenannten Selbstvornahme hat der Besteller nach vergeblicher Frist zur Nacherfüllung unter anderem das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der notwendigen Aufwendungen zu verlangen (§§ 634 Nr. 2, 637 BGB). Hierbei handelt es sich um einen Sekundäranspruch.
- Ein solches Recht sieht das Kaufrecht nicht vor.

5. Erläutern Sie die Hauptleistungspflichten beim Werkvertrag. Sind darüber hinaus auch Nebenleistungspflichten denkbar?

- Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes frei von Sach- und Rechtsmängeln verpflichtet, §§ 631, 633 BGB.
- Den Besteller trifft die Verpflichtung, das fehlerfreie Werk abzunehmen und zugleich die vereinbarte Vergütung zu entrichten, §§ 631, 640, 641 BGB.
- Bei den beiden obig genannten Pflichten handelt es sich um die Hauptleistungspflichten.
- Außerdem können von Fall zu Fall Nebenleistungspflichten bestehen.

Beispiel: Werbung des Veranstalters für ein Konzert

- Bonus: Außerdem sind Nebenpflichten denkbar.

Beispiel: Gewährleistung von Sicherheit gem. § 241 II BGB